

Tema 3

Compliance: objetivo, definición y concepto principales

1. Introducción	2
2. El Compliance y la Responsabilidad Penal.....	5
3. Delitos y Hechos de conexión	8

1. Introducción

El termino COMPLIANCE

El término Compliance (**Cumplimiento Normativo**) ha adquirido una mayor notoriedad desde la reforma del Código Penal en 2010.

Esta reforma supuso la inclusión de RESPONSABILIDAD PENAL PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS.

No obstante, el término Compliance no se agota en el ámbito penal, sino que se refiere a una realidad de cumplimiento legal y normativo mucho más amplia.

Desde el punto de vista empresarial

El Compliance alude a una diversidad de materias en las que se requiere de la empresa/empresario una conducta o comportamiento preventivo y de control, mediante una correcta identificación y evaluación de los riesgos legislativos y normativos a los que se encuentran sujetos a través de las conductas y comportamientos que se imponen a las empresas junto con directrices y recomendaciones de índole voluntario.

Desgranando lo anterior, concluimos que para la empresa existen:

- Normas de obligado cumplimiento: cuya inaplicación o desatención genera importantes consecuencias a nivel de responsabilidad (sanciones) y reputación para el empresario.
 - En esa medida, no sólo debe contemplarse la eventualidad de la RPPJ determinada en la legislación penal, sino también el sometimiento a otros riesgos normativos (p. ej. Gobierno corporativo, Protección de Datos, Blanqueo de Capitales, etc.) y reputacionales (políticas de igualdad de género, políticas de competencia, etc.).
- Estándares de conducta de desarrollo ético empresarial: seguimiento voluntario incluidos en el concepto global de Responsabilidad Social Corporativa.

RSC

Indica el compromiso voluntario de una organización, sociedad o empresa con la sociedad, el medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Se alude también a la conciliación de la vida profesional y familiar, la prevención de riesgos laborales y salud laboral, la ética en los negocios, la transparencia, la reputación y el buen gobierno corporativo.

La responsabilidad social corporativa (RSC) era un concepto empresarial emergente y se ha convertido en un imperativo esencial para las organizaciones en la actualidad. La RSC implica que las empresas, además de buscar el éxito financiero, asumen la responsabilidad de impactar positivamente en la sociedad y el medio ambiente. Por ello es importante conocer cómo algunas de las principales empresas de ámbito nacional e internacional practican este tipo de actividades y las han insertado con éxito en su modelo de negocio.

Por ello, cada empresa deberá ajustar su programa de Compliance no sólo a los riesgos generales que soporta, sino también a aquellos que responden a su actividad concreta.

Cada empresa deberá tener una política activa que incorpore los medios necesarios para detectar los riesgos normativos e implantar las medidas necesarias de prevención y, en su caso, actuación correcta.

¿Cómo? Implantando programas de *Compliance* que incorporen sistemas de evaluación de riesgos normativos, prevención y control de los mismos en base a los riesgos que soportan para verificar que se produce el requerido cumplimiento normativo y la deseable actuación conforme a la ética empresarial.

Se trata de delimitar los riesgos en base a:

- Actividad desarrollada
- Dimensión social, laboral, material
- Situación económica
- El histórico en materia de cumplimiento normativo

A PARTIR DEL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS Y MEDIANTE UN PROGRAMA ACTIVO Y EFICAZ, SERÁ POSIBLE DETERMINAR CÓMO ACTUAR PARA:

- Prevenir
- Mejorar
- Eliminar los riesgos

¿A quién afecta?

La función del Compliance engloba a **todas las personas** que tienen alguna actividad o responsabilidad relacionada con un cumplimiento normativo en la empresa, y NO únicamente a un único sector de la organización en particular. De la misma manera, NO bastará con la mera existencia de un programa, sino que deberá acreditarse su adecuación para prevenir el concreto delito que se ha cometido.

¿Qué engloba?

Documentos esenciales junto al programa de Compliance:

Código de conducta: Recoge los principios propios de la compañía y el reflejo de cara a terceros; Cómo debe ser el comportamiento de tus empleados y que éstos se sientan identificados. Por tanto, definir los valores a recoger en el código.

Política anticorrupción: Recoger las medidas y criterios a aplicar para actuar con políticas de ética profesional (ideas de control económico, regalos, atenciones prohibidas, conflictos de intereses, negociaciones comerciales, etc.).

Canal de denuncia: Incentivar la denuncia de comisiones de delito en el ámbito empresarial.

Régimen disciplinario: Previsión de un régimen sancionador acorde al ET y al Convenio Colectivo.

Contenido

LEYES

- Corporate Compliance
- Privacidad y Protección de datos
- Prevención y Blanqueo de
- Capitales
- Sociedad de la Información y
- eFirma
- Derecho de la competencia
- Etc.

CONTRATOS

- Seguimiento de los SLAs
- Acuerdos de socios
- Control cadena de subcontratados
- SAM
- Controles tecnológicos de Cloud
- Computing
- Etc.

AUTORREGULACIÓN Y ESTÁNDARES

- PCI-DSS Medios de pago
- ISO 27001
- BCRs Transferencias

- internacionales
- Autocontrol Publicidad
- Etc.

ÉTICA Y NORMATIVA INTERNA

- Código ético
- Canal de denuncia
- Clasificación de la Información
- Uso de redes sociales
- Uso de dispositivos corporativos
- Protocolos antes salida de
- empleados
- Etc.

2. El Compliance y la Responsabilidad Penal

Confusiones y errores comunes

1. "La función de Compliance en la empresa debe dedicarse exclusivamente a la prevención de delitos del Código Penal para evitar la RPPJ". → **La función no es solo la prevención de delitos, ya que también se tratan los comportamientos internos.**
2. "Lo que se trata es de que la empresa establezca controles para evitar que se cometa cualquier delito dentro de la misma". → **Solo obligación de prevenir aquellos con responsabilidad a la PJ.**
3. "Basta con enviar el Código Ético que la empresa elabora a los empleados para cumplir con la obligación". → **Es un solo punto dentro de todos los que conlleva el compliance.**
4. "El Compliance es lo mismo que la asesoría jurídica de una empresa, y al final se trata de cumplir Leyes". → **La realidad lleva a normas que implican controles dentro de los procesos de la compañía. Necesaria independencia y autonomía de la figura del CO.**
5. "Este invento anglosajón aquí no funcionará". → **Inculcar cultura de prevención de delitos.**

LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE **NO SÓLO** TIENEN COMO FINALIDAD LA EVITACIÓN DE LA CULPABILIDAD EN LA QUE PUEDA RECAER LA PERSONA JURÍDICA, SINO **PROMOVER UNA VERDADERA CULTURA ÉTICA EMPRESARIAL.**

Antecedentes y Normativa:

1. Desde el 23 de diciembre de 2010 a través de la LO 5/2010 (entrada en vigor de la reforma del Código Penal), se puede atribuir responsabilidad penal a las Personas Jurídicas.
2. Ley 37/2011, de medidas urgentes de agilización procesal que modifica la LECrim.
3. LO 7/2012, por la que se modificó el Código Penal "en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal en la Seguridad Social".
4. LO 1/2015 de Reforma del CP
 1. Tal incorporación se hizo por medio del art. 31. bis del CP.
 2. El propósito no es modificar el régimen de responsabilidad a la PJ (Persona Jurídica), sino añadir la posibilidad de ATENUAR / EXIMIR de la pena a dicha PJ.
5. Circular 1/2016 FG

Análisis del Art. 31 bis:

1. **Criterios de transferencia** de la RP distinguiendo dos clases de sujetos: a) representantes (31.bis.1.a)) y b) subordinados (31.bis.1.b))
2. Modelos de organización y control: enumera los **requisitos de la eximente** para las personas descritas en el 31.bis.1.a) [representantes].
3. Modelos de organización y control: requisitos especiales para empresas de **pequeñas dimensiones**. [Las autorizadas a presentar cuentas de pérdidas y ganancias abreviada].
4. Modelos de organización y control: enumera los **requisitos de la eximente** para las personas descritas en el 31.bis.1.b) [subordinados].
5. **Requisitos** mínimos que han de contener los "modelos de organización y control". [Los programas de Compliance].

¿Cómo se produce ese traslado de Responsabilidad?

MODELO VICARIAL:

- La Persona Jurídica NO comete delitos. No es un hecho propio de la persona jurídica.
- Los delitos son cometidos por las Personas Físicas.
- No hay una responsabilidad automática. Son necesarios una serie de hechos de conexión.

Por tanto, lo que ocurre es que, ante la comisión de determinados delitos por ciertas personas físicas, se traslada mediante ciertos hechos de conexión la responsabilidad a la PJ.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas

AFIRMAR QUE LAS SOCIEDADES SON RESPONSABLES PENALMENTE, ESTO ES, QUE PUEDEN SER SANCIONADAS, NO ES EQUIVALENTE A DECIR QUE LAS SOCIEDADES PUEDEN DELINQUIR, ESTO ES, QUE COMETEN DELITOS.

LAS SOCIEDADES NO COMETEN DELITOS, PERO SÍ SON RESPONSABLES DE LOS ACTOS QUE COMETEN LAS PERSONAS FÍSICAS QUE SON PARTE DE DICHA ORGANIZACIÓN.

3. Delitos y Hechos de conexión

Delitos por los que se transfiere la Responsabilidad Penal:

Contrabando	Tráfico ilegal de órganos
Trata de seres humanos	Prostitución / explotación sexual / corrupción de menores
Acceso ilícito a sistemas informáticos (art 197 quinquies) "Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en los artículos 197, 197 bis y 197 ter".	Estafa (art 251 bis)
Frustraciones de la ejecución / alzamiento de bienes	Insolvencias (art 261.bis) "El que en procedimiento concursal presentare, a sabiendas, datos falsos relativos al estado contable, con el fin de lograr indebidamente la declaración de aquel".
Daños informáticos (art 264 quarter) "El que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese o hiciese inaccesibles datos informáticos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años. Ver jurisprudencia"	Contra la Propiedad Intelectual e Industrial, el mercado y los consumidores y corrupción entre particulares (art 270 – 288).

Blanqueo de capitales (art 302.2) “El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos”	Financiación ilegal de partidos políticos
Contra la ordenación del territorio	Contra los derechos de ciudadanos extranjeros
Vertido de radiaciones Contra la salud pública	Riesgos por explosivos Contra los recursos naturales y el medio ambiente
Falsificación de moneda	Falsificación de tarjetas de crédito, débito y cheques viaje
Delitos de odio y enaltecimiento del terrorismo	Financiación del terrorismo
Delitos contra la Hacienda Pública y Seguridad Social (art 310.bis)	Cohecho (art 427 bis) “La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar”

Tráfico de influencias (art 430)**Tráfico de drogas**

"El particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaleándose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero"

Hechos de conexión

Tendrán que demostrarse 2 cuestiones diferentes:

- 1.- La realización personal del hecho y la individualización de la responsabilidad de cada persona física (que una Persona Física cometa alguno de los anteriores delitos)
- 2.- Verificar, una vez producida la comisión, si se cumplen los criterios de transferencia de la RP a la PJ: que se den los "hechos de conexión".

¿QUÉ SON LOS HECHOS DE CONEXIÓN?

Son los criterios de transferencia o derivación de la RP desde la actuación de determinadas personas físicas, y son:

1. **Que la comisión del delito sea por determinadas personas idóneas**
 - Representantes / Subordinados
2. Que dicha actuación reporte un beneficio directo o indirecto para la Persona Jurídica
3. Que se actúe "EN NOMBRE O POR CUENTA DE"
4. Ocasionándose un incumplimiento grave de los deberes de **vigilancia, control y supervisión.**

Fase 1: Comisión del delito por determinadas personas.

- 1er Círculo (art 31.bis.1º.a): Son las PF con **poder y representación societaria de máxima autoridad**. Contiene 3 subniveles:
 - Los “**Representantes legales**” → **Administradores de hecho y de derecho**.
 - Quienes “actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la PJ, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica”. → **Cargos directivos, puestos de mando, quienes votan o deciden**.
 - Aquellos que “ostentan facultades de organización y control dentro de la misma”. → **Cargos y mandos intermedios con atribución de dichas facultades**.
 - Aquellos sujetos con capacidad de control o decisión por la empresa.
- 2º Círculo (art 31.bis.1º.b): Aquellas PF **subordinadas** en la escala jerárquica societaria a la autoridad de las antes mencionadas, Y, que se produzca un **incumplimiento grave de los deberes de vigilancia, control y supervisión por el nivel 1º nivel**.
 - Incluidos los trabajadores autónomos y las subcontratas.

Fase 2: “En nombre o por cuenta de”

Fase 3: “en su beneficio directo o indirecto”

- Recoge cualquier clase de ventaja para la sociedad, entendiéndose incluido cualquier **ahorro de costes** para la empresa, obtenidos a partir del comportamiento delictivo.

Fase 4: “Deber de vigilancia”

- Dicho deber de control es externo y superior a las personas encargadas de la tarea.
- Obliga a definir en los programas los deberes de los sujetos obligados como responsables de dicho cumplimiento.

CONDICIONES PARA EXIMIR DE RESPONSABILIDAD AL 1er NIVEL (art 31.bis.1º.a) - (ART 31.BIS.2º)

- I. El Órgano de Administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de comisión.
- II. La supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos e iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la PJ.
- III. Los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención.
- IV. No se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición II.

CONDICIONES PARA EXIMIR DE RESPONSABILIDAD AL 2do NIVEL (art 31.bis.1º.b) - (ART 31.BIS.4º)

- I. Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra b) del apartado 1º, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

REQUISITOS A CUMPLIR DE LOS MODELOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (art 31.bis.5º) = Requisitos de los programas de Compliance

1. Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.
2. Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la PJ, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquellos.
3. Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.
4. Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención. (*Canal de denuncias*)
5. Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo. (*Código disciplinario*).
6. Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Por tanto, el requisito necesario para empezar a contemplar esa ATENUACIÓN/EXIMENTE de la pena es que la organización tenga un **PROGRAMA DE COMPLIANCE**.